

Roxin (Claus Roxin)

La teoría del delito en la discusión actual — trad. Manuel Abanto Vásquez, Grijley

Línea teórica: Funcionalismo teleológico-racional orientado por política criminal; dogmática penal que confronta la ley vigente con los mandatos constitucionales de un Estado social y de Derecho, practicando una política criminal científica independiente.

Tesis central

La imputación objetiva (creación de riesgo no permitido y realización del riesgo en el ámbito de protección del tipo) es el corazón de la tipicidad objetiva y sustituye la causalidad como criterio central. La pena no puede imponerse sólo por culpabilidad: requiere necesidad preventiva. La dogmática debe ser científica pero orientada por la política criminal constitucional: concretizar los mandatos del Estado social y de Derecho sin caer en un funcionalismo sistemático neutro respecto al contenido.

Panorama

Colección de ensayos y conferencias de Roxin (traducidos al español por Abanto Vásquez) que exponen su pensamiento sobre las tareas futuras de la ciencia penal: dogmática sistemática como eje central, pero abierta a nuevos problemas sociotécnicos (criminalidad económica, riesgos masivos, bioética); rechazo del funcionalismo puro (tipo Jakobs) en favor de un funcionalismo con fundamento político-criminal basado en la Constitución; énfasis en la imputación objetiva como categoría central; teoría de los fines de la pena (prevención especial y general) como límite de la punibilidad; y la culpabilidad redefinida como responsabilidad preventiva.

Postura en la teoría del delito

Acción

Manifestación de la voluntad del autor que incide en el mundo exterior; concepto personal que vincula el comportamiento humano con sus consecuencias. Para Roxin, la acción es el comportamiento controlado por la voluntad del sujeto que realiza el tipo.

Tipicidad objetiva

Descripción típica del comportamiento y sus resultados. La tipicidad objetiva se estructura mediante el análisis de imputación objetiva (no causalidad): creación de riesgo jurídicamente desaprobado, realización del riesgo creado, y que la lesión se produzca en el ámbito de protección (fin de protección) del tipo penal.

Imputación objetiva

Concepto central de Roxin: va más allá de la causalidad. Requiere: (1) creación de un riesgo no permitido por el autor; (2) realización del riesgo en el resultado lesivo; (3) que la lesión ocurra en el ámbito de protección (fin de protección) del tipo. Esto permite excluir responsabilidad en casos de cursos causales anormales, intervención de terceros, o riesgos permitidos. Sustituye la dicotomía acción-resultado por imputación racional del riesgo.

Tipo subjetivo · Dolo

El dolo es conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo. Roxin lo estructura como dolo de resultado y dolo de acción según la tipología de cada delito. Critica el 'dolus eventualis' normativizado (doctrina del peligro de dolo) y exige claridad conceptual en la representación de las circunstancias del hecho.

Error de tipo

El error sobre elementos del tipo elimina el dolo (error de tipo esencial) o lo reduce (error de tipo no esencial). Roxin distingue entre error sobre circunstancias fácticas y error sobre elementos normativos; rechaza que el error de subsunción sea error de tipo. Considera que el error de tipo invencible excluye responsabilidad; el vencible reduce a imprudencia cuando la ley lo permite.

Antijuridicidad

Lesión del bien jurídico protegido por el tipo. Roxin enfatiza que la antijuridicidad material radica en la violación de los derechos fundamentales y los bienes jurídicos que la Constitución protege. Las causas de justificación (legítima defensa, estado de necesidad) se fundan en que la conducta no lesiona realmente el bien jurídico o que la lesión está permitida por la ponderación constitucional.

Culpabilidad

Redefinida por Roxin como responsabilidad preventiva: culpabilidad + necesidad preventiva de pena. No es sólo reprochabilidad moral, sino capacidad del sujeto de motivarse por la norma y, simultáneamente, que la pena sea preventivamente necesaria (prevención general positiva de estabilización de confianza en la norma, o prevención especial de no-reincidencia). Esto permite excluir pena en casos de ausencia de necesidad preventiva pese a haber culpabilidad (p. ej. desistimiento, estado de necesidad exculpante).

Error de prohibición

Error sobre la licitud (antijuridicidad) de la conducta. Roxin lo divide en error de mandato (casos de omisión) y error genérico sobre prohibición. El error de prohibición invencible excluye culpabilidad; el vencible la atenúa. Rechaza teorías psicologicistas: el error debe ser normativo, es decir, sobre la prohibición jurídica, no sobre la motivación subjetiva.

Tentativa

Realización de actos que constituyen inicio de ejecución del delito. Roxin critica la teoría de actos parciales y propone la teoría del peligro próximo: comienzo cuando el autor ejecuta acciones que crean un peligro inmediato y concreto para el bien jurídico. El desistimiento es acto voluntario que impide la consumación; Roxin lo fundamenta en la prevención especial (no necesidad de pena si el autor se retrae).

Autoría y participación

Autoría es dominio del hecho (concepto central): el autor es quien domina el proceso criminal decisivamente. Distingue: (1) autoría inmediata (ejecución directa); (2) autoría mediata (uso de tercero como instrumento); (3) coautoría (dominio conjunto); (4) instigación (inducción al delito); (5) complicidad (apoyo no esencial). Para aparatos de poder (criminalidad organizada): dominio de la organización como forma de autoría mediata en estructuras jerárquicas donde el hombre de atrás domina a través de la fungibilidad de ejecutores.

Posturas en debates clave

- **Imputación objetiva vs. causalidad.** Roxin sustituye la causalidad naturalística por imputación objetiva: no basta nexo causal, sino creación de riesgo no permitido y realización del riesgo en el ámbito de protección del tipo. Rechaza la fórmula de la *conditio sine qua non* como insuficiente. (Presentación (p. 645); Ensayo sobre imputación del resultado (p. 165+))
- **Culpabilidad como responsabilidad preventiva.** Roxin rechaza la culpabilidad puramente retributiva. La culpabilidad exige: (a) reprochabilidad del autor, (b) necesidad preventiva de pena. Sin necesidad preventiva no hay pena legítima, incluso con culpabilidad plena (ej: desistimiento voluntario, estado de necesidad exculpante). (Teoría de fines de la pena (p. 68+); Política criminal y dogmática (p. 41+))
- **Funcionalismo teleológico-racional vs. funcionalismo sistemático puro (Jakobs).** Roxin critica a Jakobs por un funcionalismo aislado: su teoría de sistemas es neutra respecto al contenido (puede estabilizar cualquier sistema, liberal o totalitario), carece de contenido político-criminal reformador y renuncia a criticar el statu quo legislativo. Roxin defiende funcionalismo orientado por valores constitucionales (Estado de Derecho, derechos fundamentales). (Política criminal y dogmática hoy en día (p. 47+))
- **Error de tipo vs. error de prohibición.** Roxin rechaza la teoría psicologicista: ambos son errores normativos. El error de tipo (sobre circunstancias) afecta el dolo; el error de prohibición (sobre la antijuridicidad) afecta la culpabilidad. Ambos pueden ser vencibles o invencibles según si el autor pudo o no alcanzar el conocimiento debido. (Acerca del error en el Derecho penal (p. 175+))
- **Desistimiento de la tentativa: voluntariedad normativa vs. psicológica.** Roxin propone criterio normativo: el desistimiento es acto voluntario en sentido jurídico-penal (no psicológico). La voluntariedad existe si el autor podía retractarse. Se fundamenta en prevención especial: cuando el autor se desiste, no hay necesidad de pena para evitar su reincidencia ni para intimidar a otros. (Acerca de la tentativa en el Derecho penal (p. 297+))
- **Dominio de la organización en criminalidad de aparatos de poder.** Roxin aplica dominio del hecho a estructuras organizadas: el hombre de atrás domina a través de fungibilidad de ejecutores. Esto permite imputar autoría mediata a jerarcas que no ejecutan directamente pero controlan el aparato. Rechaza teorías que exigen vínculo personal directo. (Dominio de la organización y resolución al hecho (p. 427+))
- **Política criminal científica vs. positivismo jurídico.** Roxin defiende que la ciencia penal no debe limitarse a interpretar la *lex lata*, sino practicar política criminal: diseñar derecho penal futuro mediante proyectos de reforma. Esto no es político partidario sino científico-constitucional: concretar mandatos del Estado social y de Derecho. (La ciencia jurídico-penal ante las tareas del futuro (p. 27+))
- **Necesidad preventiva como límite de la culpabilidad.** Roxin integra la teoría de fines de la pena en la culpabilidad misma: no basta culpabilidad, es menester que la pena sea preventivamente necesaria. Esto permite excluir punición en casos de ausencia de necesidad (estado de necesidad exculpante, inexigibilidad, etc.) pese a culpabilidad probada. (Cambios en la teoría de los fines de la pena (p. 67+); Política criminal (p. 41+))

Glosario

- **Imputación objetiva:** Criterio de atribución del resultado lesivo al autor que va más allá de la causalidad: requiere creación de riesgo jurídicamente desaprobado, realización del riesgo en el resultado, y que la lesión ocurra en el ámbito de protección (fin de protección) del tipo penal. Sustituye la *conditio sine qua non* por análisis racional del riesgo.
- **Dominio del hecho:** Criterio central de Roxin para distinguir autoría de participación: es autor quien domina el proceso criminal decisivamente. Incluye autoría inmediata (ejecución propia), autoría mediata (a través de tercero), coautoría (dominio conjunto) y dominio de la organización (en aparatos de poder).
- **Culpabilidad (redefinida como responsabilidad preventiva):** Para Roxin: culpabilidad + necesidad preventiva de pena. No es sólo reprochabilidad moral, sino la convergencia de capacidad motivación del autor y utilidad preventiva de la pena. Permite excluir punición sin culpabilidad formal si falta necesidad preventiva.

- **Política criminal científica:** Elaboración de conceptos de reforma independientes del legislador, presentados a la realidad jurídica para discusión y motivar iniciativas legislativas. Basada en mandatos constitucionales del Estado social y de Derecho, no en posiciones políticas partidarias.
- **Funcionalismo teleológico-racional:** Metodología de Roxin: funcionalismo que no es neutral sino orientado por fines (telos) constitucionales. Rechaza funcionalismo puro (Jakobs) que no discrimina entre sistemas; Roxin defiende concreción de derechos fundamentales y principios de Estado de Derecho como límites materiales.
- **Riesgo permitido:** Comportamiento socialmente tolerado aunque crea cierto riesgo: no es típico porque el riesgo no es jurídicamente desaprobado. Ejemplos: circulación vehicular normal, intervenciones quirúrgicas. La categoría se estructura mediante imputación objetiva, no por naturalidad de la conducta.
- **Fin de protección (del tipo):** Propósito del tipo penal: qué bien jurídico protege y frente a qué riesgos. Solo es típica la lesión que realiza el riesgo que el tipo pretende evitar. Elemento crucial para determinar si el resultado es imputable objetivamente al autor.
- **Desistimiento voluntario:** En tentativa inacabada: retractación del autor antes de consumar. Roxin lo fundamenta en prevención especial (no necesidad de pena si se retrae) y exige voluntariedad en sentido normativo (no psicológico): que el autor haya podido retractarse.

Mapa de capítulos

I. La ciencia jurídico-penal ante las tareas del futuro p. 3-40

Programa de futuro para la ciencia penal: (1) sistematización y dogmática como eje, (2) reexaminación de conceptos antiguos y nuevos, (3) base supranacional, (4) asesoramiento a jurisprudencia y legislación, (5) política criminal científica, (6) derecho penal supranacional. Critica la ley que ha dejado problemas sin resolver y propone incorporación de expertos en procesos legislativos.

II. Política criminal y dogmática penal hoy en día p. 41-60

Defensa de la teoría de los fines de la pena (prevención especial + general) como fundamento de la culpabilidad redefinida como responsabilidad preventiva. Crítica al funcionalismo puro de Jakobs por su neutralidad respecto al contenido constitucional. Defiende dogmática creativa orientada por valores de Estado social de Derecho.

III. Cambios en la teoría de los fines de la pena p. 67-120

Síntesis entre prevención general positiva (estabilización de confianza en la norma) y prevención especial (no-reincidencia) como teoría de pena. Diversificación de fines según estadios (conminación, imposición, ejecución). Integración en la culpabilidad: necesidad preventiva como elemento de responsabilidad, no mero límite cuantitativo.

IV. Observaciones a la prohibición de regreso p. 85-112

Análisis de cuándo el comportamiento de un tercero (delictivo o no) impide atribuir responsabilidad al primer actuante. Roxin rechaza teorías basadas en 'propiedad responsabilidad' y propone criterio de riesgo permitido: si el riesgo generado cae en riesgo permitido del tercero, no hay imputación.

V. Acerca de la imputación del resultado en cursos causales puestos en marcha anticipadamente p. 165-173

Problema de si una tentativa inacabada o un acto preparatorio pueden fundar un dolo consumado. Roxin diferencia según si la resolución (resolución al hecho) se ha formado; propone que solo comportamientos que realizan la resolución al delito permiten imputación de consumación.

VI. Acerca de la normativización del dolus eventualis

p. 169-173

Crítica a la 'doctrina del peligro de dolo' que normativiza el dolo eventual. Roxin exige claridad conceptual: el dolo eventual no puede relativizarse por consideraciones sobre peligrosidad social; debe mantenerse el elemento cognitivo (representación del riesgo).

VII. Acerca del error en el Derecho penal

p. 175-216

Clasificación exhaustiva: error de tipo (afecta dolo), error de prohibición (afecta culpabilidad), error sobre circunstancias justificantes, error sobre circunstancias exculpantes. Roxin rechaza teoría psicologista; ambos son errores normativos. Criterios de vencibilidad e invencibilidad.

VIII. Las causas de justificación y exculpación

p. 217-258

Diferenciación crucial: justificación excluye antijuridicidad (permiso legal), exculpación excluye culpabilidad (reprochabilidad). Roxin rechaza teorías unitarias. Significación práctica para doble vía, punibilidad de participación, legítima defensa, tratamiento del error. Reconstrucción sistemática desde valores constitucionales.

IX. Acerca del consentimiento en el Derecho penal

p. 269-295

El consentimiento válido es causa de exclusión del tipo: si hay consentimiento válido, típicamente no hay lesión del bien jurídico (ej: cirugía con consentimiento). Roxin analiza tipos que no admiten consentimiento, momento y revocación del consentimiento.

X. El principio de culpabilidad y sus cambios

p. 297-325

Evolución histórica del principio de culpabilidad en la dogmática penal alemana. Roxin lo redefine como responsabilidad preventiva, integrando la culpabilidad con la necesidad preventiva de pena. Cambios en el tratamiento de circunstancias personales, inexigibilidad, y conflictos de conciencia.

XI. El estado de necesidad exculpante según el art. 35 CP

p. 327-367

Ubicación sistemática: exculpación (no justificación). Requisitos: peligro actual, bien jurídico mayor, no causante del peligro el agente. Roxin lo fundamenta en ausencia de necesidad preventiva de pena (prevención especial + general insatisfecha). Analiza bienes susceptibles, participación, medición de pena.

XII. Acerca del fundamento penal de la tentativa

p. 372-390

Crítica a teoría de actos parciales de jurisprudencia. Propone teoría del peligro próximo: tentativa es inicio de ejecución que crea peligro inmediato y concreto al bien jurídico. Critica teorías subjetivas y de la impresión. Fundamenta en que ya existe peligro tipificable.

XIII. Acerca de la tentativa en el Derecho penal

p. 392-435

Análisis exhaustivo de delimitación entre actos preparatorios y tentativa (inicio de ejecución), desistimiento voluntario (fundamento preventivo-especial), tentativa acabada vs. inacabada, desistimiento como salvaguarda de la responsabilidad. Roxin rechaza teoría puramente psicológica de la voluntariedad.

XIV. Delimitación entre tentativa inidónea y delito putativo p. 437-467

Tentativa inidónea: acción que no produce resultado por circunstancias fácticas desconocidas. Delito putativo: error sobre la existencia del tipo. Roxin rechaza teoría del error fundamentador de tentativa; propone solución diferenciadora según naturaleza del error y posición subjetiva.

XV. Formas de participación en el delito: estado actual de la discusión p. 468-488

Exposición de jurisprudencia BGH sobre participación. Autoría inmediata, autoría mediata, coautoría, inducción, complicidad. Roxin sistematiza mediante concepto de dominio del hecho: quien domina decisivamente el proceso es autor; participante es quien colabora sin dominio.

XVI. Acerca del fundamento penal de la participación p. 489-510

Participación no es accesoria pura: tiene presupuestos independientes. Requiere: (1) bien jurídico lesionado también protegido frente partícipe, (2) partícipe tiene dolo de realización del tipo, (3) admisión en dolo de intenciones relacionadas, (4) inducción exige incitación dirigida, (5) complicidad requiere referencia delictiva de sentido.

XVII. Dominio de la organización y resolución al hecho p. 427-485

Concepto de Roxin aplicado a criminalidad de aparatos: en estructuras jerárquicas, el hombre de atrás domina mediante fungibilidad de ejecutores. Rechaza autoría mediata simple; propone dominio de la organización como forma propia de autoría. Aplicación a criminalidad de Estado.

XVIII. ¿Qué es la complicidad? p. 490-560

Complicidad como colaboración no esencial (distinta de inducción y coautoría). Requisitos: causalidad (incremento de riesgo), dolo (conocimiento de resolución delictiva). Roxin rechaza teoría de 'promoción' genérica; exige referencia del acto a la comisión del delito concreto. Análisis de 'acciones cotidianas' reprochables.